

1002576-89.2022.8.26.0191

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Responsabilidade do Fornecedor

Magistrado: LUCIANA DO CARMO NOGUEIRA

Comarca: Ferraz de Vasconcelos

Foro: Foro de Ferraz de Vasconcelos

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 01/11/2022

... da natureza do delito, seja ele roubo ou, como no caso, furto mediante fraude, o autor não realizou as operações e o réu foi comunicado do ocorrido e instado a se posicionar.

Note-se que o requerido não logrou êxito em comprovar a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor. Isto porque, o acionado falhou na prestação dos serviços, seja deixando vaziar os dados pessoais e bancários ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ferraz de Vasconcelos

Foro de Ferraz de Vasconcelos

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Santos Dumont, 1535, Ferraz de Vasconcelos-SP - cep 08531-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

Processo Digital Nº 1002576-89.2022.8.26.0191 - LAUDA

SENTENÇA

Processo Digital Nº:

1002576-89.2022.8.26.0191

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - Responsabilidade do Fornecedor

Requerente:

José Sabino de Souza

Requerido:

Banco do Brasil S.a

Prioridade Idoso

Juíza de Direito: Doutora LUCIANA DO CARMO NOGUEIRA

VISTOS.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por JOSÉ SABINO DE SOUZA em face de BANCO DO BRASIL S/A.

Em síntese, aduz o autor ter recebido uma ligação telefônica de uma pessoa que se apresentou como preposto do acionado e comunicou a clonagem de seu cartão de crédito, orientando-o a destruir o cartão e o entregar a um motoboy.

Posteriormente, constatou a cobrança de diversas operações bancárias desconhecidas e descobriu se tratar de golpe. Pleiteia a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R\$ 2.484,35 e danos morais no valor de 10 salários mínimos.

Regularmente citado, o réu apresentou contestação às fls. 82/128 suscitando a preliminar de ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir. No mérito, impugna os fatos alegados. Argumenta pela validade das transações financeiras, em decorrência do uso do cartão e senha pessoais. Defende a culpa exclusiva, pois a parte entregou o cartão de crédito, sendo vítima da atuação criminosa de terceiros. Pleiteia pela improcedência da ação.

Intimadas, a parte autora não manifestou o desejo pela produção de outras provas (fl. 259) e a parte ré deixou decorrer in albis o prazo (fl. 257), motivo pelo qual passo a decidir.

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Nº 9.099/1995. Fundamento e Decido.

O pleito comporta apreciação antecipada, nos termos do artigo 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, pois o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença, quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência. Já decidiu o Egrégio Supremo Tribunal Federal que:

"(...) entre os poderes conferidos ao Juiz, na direção do processo, está o de determinar as provas necessárias à instrução do feito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias (CPC, art. 130). Portanto se o Magistrado indefere prova requerida pela parte por julgá-la desnecessária, atua em conformidade estrita com a lei." (A.I. Nº 142.023-5/SP - Relator(a) Ministro(a) Sepúlveda Pertence - citação tirada de Venerável Acórdão inserto na RT 726 / 247 - Relatado pelo Desembargador Mohamed Amaro - Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo)

Por conta disso, vislumbro que a documentação carreada aos autos é suficiente para o deslinde da causa, para o que será despendida a elucidação dos fatos por meio de produção de prova testemunhal e/ou documental acessória.

A preliminar de ilegitimidade passiva confunde-se com o mérito e com ele será analisada.

Afasto a preliminar de falta de interesse de agir, pois ele existe quando o provimento jurisdicional é necessário para obtenção da tutela pretendida, bem como quando houver utilidade na tutela almejada e adequação do pedido com a via processual eleita.

No mérito, os pedidos são parcialmente procedentes, senão vejamos.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação havida entre as partes submete-se à regência das normas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, consoante interpretação do artigo 2º, caput, e do artigo 3º, caput, ambos da Lei Nº 8.078/1990.

Trata-se de entendimento pacificado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme Súmula Nº 297, segundo a qual as atividades de natureza bancária se enquadram na categoria de serviços, para fins de configuração da relação de consumo.

E, sendo de consumo a relação mantida entre as partes e verossímeis os fatos aduzidos na inicial, impõe-se a inversão do ônus da prova, na forma como dispõe o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, em se tratando de fato negativo (não realização das operações bancárias), não se pode exigir do requerente a demonstração do alegado. O ônus da prova, então, incumbia ao demandado, que falhou neste ponto.

O que se extrai dos autos é que o demandado não foi capaz de trazer provas de que as transações impugnadas pelo demandante foram por ele realizadas. Limitou-se a alegar culpa exclusiva do autor, que entregou seu cartão a terceiro. Contudo, o requerente apenas o fez porque foi vítima de furto mediante fraude.

O demandante foi vítima de criminosos, na data de 14/MAIO/2021, -Boletim de Ocorrência Nº 1547/2021 (fls. 09 e 10)- que, após se identificarem como prepostos do banco por meio de um telefonema, informaram que o cartão do autor havia sido clonado e que ele deveria corta-los na metade e entrega-los ao motoboy que iria até sua residência, o que foi feito.

No mesmo dia, contudo, após constatar operações realizadas com seus cartões, entrou em contato com o réu, solicitando seu bloqueio e cancelamento.

A despeito da comunicação, constatou compras e saques, sendo estes no total de R\$2.484,35, por meio da utilização de cartões de débito e crédito.

A dinâmica narrada pelo autor não deixa dúvidas de que as operações sub judice não são de sua autoria e, portanto, não pode ser responsabilizado por tais atos.

Frise-se que, o demandante de imediato comunicou o ocorrido ao demandado, que deixou de tomar as providências necessárias para evitar prejuízos e continuou a cobrar pelas compras e saques que sabidamente o consumidor não realizou ou autorizou.

Independente da natureza do delito, seja ele roubo ou, como no caso, furto mediante

fraude, o autor não realizou as operações e o réu foi comunicado do ocorrido e instado a se posicionar.

Note-se que o requerido não logrou êxito em comprovar a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor. Isto porque, o acionado falhou na prestação dos serviços, seja deixando vaziar os dados pessoais e bancários do demandante, seja deixando de notar a quebra no padrão de consumo, que ultrapassou, inclusive, o limite concedido, fracassando no dever de vigilância, devendo responder pelas vicissitudes decorrentes.

Como dito, o requerente foi vítima de furto mediante fraude, uma prática denominada "golpe do motoboy", consistente no contato telefônico por terceiro que se passa como representante do banco, possuindo informações pessoais e bancárias, aponta uma suposta transação fraudulenta e apresenta como solução a entrega dos cartões ao motoboy.

Veja-se o entendimento jurisprudencial em casos tais:

"Recurso Inominado - Fraude bancária - ligação interceptada - golpe do Motoboy - inexigibilidade de valores - Artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor - Responsabilidade Objetiva da Instituição Financeira - Multa mantida - Sentença mantida - Recurso não provido - Condenação nas verbas de sucumbência." (Recurso inominado Nº 0010918-88.2018.8.26.0016 - Nona Turma Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo - Relator(a) Dr.(a) Juiz(a) ELIANE DA CAMARA LEITE FERREIRA - j. 24/10/2018).

"APELAÇÃO. AÇÃO RESTITUIÇÃO DE VALORE C.C. PEDIDOS DECLARATÓRIO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUTOR QUE FOI VÍTIMA DE ESTELIONATÁRIOS QUE, MEDIANTE FRAUDE, LOGRARAM OBTER SEUS DADOS PESSOAIS E O CARTÃO DE CRÉDITO ADMINISTRADO PELOS RÉUS, BANCO BRADESCO E VISA DO BRASIL - "GOLPE DO MOTOBOY" - RELAÇÃO DE CONSUMO - SÚMULAS 297 E 479 DO E. STJ - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO EVIDENCIADA - OPERAÇÕES SUCESSIVAS NO MESMO DIA, COM INTERVALOS CURTOS E EM VALORES EXPRESSIVOS, COMPLETAMENTE INCOMPATÍVEIS COM O PERFIL DO USUÁRIO - CONTEXTO FÁTICO QUE TORNA ESCUSÁVEL O ENGANO DO CONSUMIDOR E EVIDENCIA HIPÓTESE DE FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DOS RÉUS - TRANSAÇÕES DECLARADAS INEXIGÍVEIS, COM ESTORNO DO VALOR QUE FOI PAGO - AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE - SENTENÇA CONFIRMADA. - RECURSOS DESPROVIDOS." (grifei) (Recurso de Apelação Cível Nº 1063829-34.2020.8.26.0002 - 22ª Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Relator(a) Desembargador(a) Edgard Rosa - j. 31/08/2022)

Note-se que é utilizado ardil apto a enganar e iludir o homem médio, não cabendo a tese de exclusão da responsabilidade por culpa exclusiva do autor ou conduta de terceiro.

Ora, o dever de vigilância nos sistemas e dados de que tem conhecimento em razão da sua atuação é dos bancos e não dos consumidores. Assim, o demandado assumiu e deve suportar os riscos de sua atividade.

Destarte, a legislação consumerista enquadra o requerente como parte economicamente hipossuficiente em relação ao requerido, sendo dever da instituição acionada oferecer meios seguros e eficazes de realização de negócios jurídicos, a fim de equilibrar a relação entre as partes.

Aplica-se ao caso a Súmula Nº 479 do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." (Súmula Nº 479 - Segunda Seção - j. 27/06/2012 - D.J.E. 1º/08/2012)

A responsabilidade do demandado é objetiva, devendo a instituição financeira assumir a responsabilidade exclusiva pelos riscos da atividade. É o que a doutrina e jurisprudência entenderam por bem denominar riscos do empreendimento.

Em sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do réu se aperfeiçoa mediante o concurso de 03 (três) pressupostos verificados no caso, quais sejam, a demonstração da falha do serviço (omissão quanto à segurança de seus sistemas), o dano dela decorrente e o nexo de causalidade entre o defeito do serviço e o dano, não havendo que se falar de culpa, a teor das orientações constantes do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Evidente que houve falha na prestação de serviço pelo réu, portanto, deve ser responsabilizado pelo erro.

Portanto, a condenação em danos materiais é medida a ser imposta.

Também é o caso de danos morais, pois as razões apontadas, por si só, são suficientes para acolher o pedido de indenização, uma vez que, apesar do não reconhecimento das transações bancárias e da solicitação de cancelamento dos cartões e movimentações, o réu, sob argumento de análise em andamento, protelou a resposta até o momento. Soma-se a isso, o fato de o autor ter ficado privado de seu dinheiro, tendo que arcar, além dos saques feitos, com os juros e impostos, devidos por ter sido excedido seu limite, para não ter seu nome negativado.

Cumprе ressaltar que o cabimento do dano moral na espécie, in casu, de modo considerável, é in re ipsa, que dispensa prova de maiores reflexos, patrimoniais ou morais.

Aprofundando-se sobre a questão, tem-se que, além de todo o transtorno por que passou o demandante, que ficou desamparado na tentativa de solução pela via administrativa, trata-se de pessoa idosa (fl. 09).

Como se trata de dano moral, desnecessária a demonstração efetiva do prejuízo como quer a ré, uma vez que o sentimento de vergonha, o sofrimento, a insegurança, o desequilíbrio emocional são reflexos advindos desse estado complexo a que a pessoa é submetida.

Assim, os fatos descritos no pedido inicial geram algum dissabor. Não que seja imenso, comparável à perda de ente querido ou outro fato marcante, mas um incômodo que irrita o consumidor e retira-o de seu cotidiano. Com tal frustração e, principalmente, com os fatos que a sucedem, nasce a pretensão indenizatória, que deve ser adequadamente quantificada.

No presente caso, é cabível a indenização por danos morais, conforme a jurisprudência da Justiça Paulista:

"AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. "Golpe do Motoboy". Cartão de crédito. Autora ludibriada por estelionatários que se fizeram passar por funcionários da instituição financeira. Responsabilidade do fornecedor pelo fato do produto, à luz do Código de Defesa do Consumidor. Falha na prestação de serviços evidenciada. Risco da atividade. Circunstâncias do caso a ensejar o reconhecimento do dano moral indenizável. Valor da indenização majorado para R\$ 10.000,00, adequado aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Sentença reformada em parte. Recurso da autora provido e improvido o apelo do réu."

(Recurso de Apelação Cível Nº 1011384-98.2021.8.26.0068 - 38ª Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Relator(a)

Desembargador(a) Flávio Cunha da Silva - j. 1º/08/2022)

Neste passo então, cumpre a fixação do quantum a ser pago a título restitutivo. Para fixação do mesmo, desta vez toma-se a lição doutrinária de Pontes de Miranda que assim leciona:

"(...) o dano moral, se não é, verdadeiramente, dano suscetível de fixação pecuniária, tem-se de reparar equitativamente." (in "Tratado de Direito Privado" - Tomo 54 - parágrafo 5.536 - Nº 1 - página 61 - apud Vair Gonzaga - da Indenização - Editora de Direito - página 392)

À míngua de maiores elementos, utilizando-se do prudente arbítrio "outorgado" pela lição acima, fixo o valor devido no importe de R\$2.424,00, ante o transtorno pelo qual passou o consumidor.

Desnecessárias, pois, outras considerações.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, com resolução do mérito, para CONDENAR o réu a pagar ao autor o valor de R\$ 2.484,35, corrigido pela Tabela Prática de Atualização Monetária do Poder Judiciário e acrescida de juros de 1% a.m. desde a citação e CONDENAR o demandado a pagar ao demandante a quantia de R\$2.424,00, a título de indenização por danos morais, atualizada monetariamente desde a presente data (Súmula Nº 362 do Colendo Superior Tribunal de Justiça) e com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados desde a citação.

Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios nesta fase processual, nos termos do artigo 55 da Lei Nº 9.099/1995.

PROCEDIMENTO ADOTADO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA:

- 1-) Com o trânsito em julgado, o(a)(s) réu(ré)(s) poderá(ão) dar-se por intimado(a)(s) e oferecer em pagamento voluntário o valor que entender(em) devido, conforme artigo 526, do Novo Código de Processo Civil.
- 2-) Caso NÃO exista o pagamento nos moldes acima referidos, fica(m) o autor(a)(s), ao ser(em) intimado(a)(s) da sentença, também cientificado(a)(s) de que deverá(ão) requerer a intimação do(a)(s) devedor(a)(s), após o trânsito em julgado da sentença, para pagamento do valor devido e já calculado nos exatos termos do artigo 524, do Novo Código de Processo Civil.
- 3-) Com a distribuição do Cumprimento de Sentença e inexistindo outras pendências, ARQUIVE-SE DEFINITIVAMENTE este feito de conhecimento. Do contrário, na omissão do(a)(s) vencedor(a)(s) e decorridos 30 (TRINTA) DIAS do trânsito em julgado, ARQUIVE-SE PROVISORIAMENTE este processo.

Para oposição de Recurso Inominado, o preparo recursal corresponderá: A) à taxa judiciária de ingresso, no importe de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, observado o valor mínimo de 05 (cinco) UFESP's; B) à taxa judiciária referente às custas de preparo, no importe de 4% (quatro por cento) sobre o valor atualizado fixado em sentença (se líquido), ou sobre o valor atualizado fixado equitativamente pelo(a) Meritíssimo(a) Juiz(a) de Direito (se ilíquido), ou ainda 4% (quatro por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa na ausência de pedido condenatório; C) às despesas processuais referentes a todos os serviços forenses eventualmente utilizados (despesas postais, diligências do Oficial de Justiça, taxas para pesquisas de endereço nos sistemas conveniados, custas para publicação de editais, etc).

O recolhimento deverá ser feito em Guia DARE - Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais - Demais Receitas (Código 230-6 - para os itens A e B), e em Guia FEDTJ (para o item C), de acordo com o previsto pelo Provimento C.G. Nº 33/2013 e pelo Provimento C.G. Nº 54/2016.

Observem, de todo modo, as disposições do artigo 4º, incisos I e II, da Lei Estadual Nº 11.608/2003, combinado com o artigo 54, parágrafo único, da Lei Nº 9.099/1995, e as instruções sobre o tema, contidas no Comunicado C.G. Nº 1.530/2021.

As custas recursais deverão ser recolhidas integralmente por ocasião da oposição do Recurso Inominado, ficando o(a)(s) recorrente(s) desde já advertido(a)(s) de que, em sede de Juizados Especiais, "o Recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva" (Enunciado Cível FONAJE Nº 80), observado que não haverá intimação pela serventia judicial para o complemento das custas, limitando-se a secretaria judicial apenas à conferência dos valores recolhidos, pois não é sua atribuição a elaboração de cálculos de forma prévia.

P.I.C.

Ferraz de Vasconcelos, 1 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA